

1501241-36.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO JOSE ALGUZ DA SILVEIRA

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... condenatório no tocante ao delito de tráfico de drogas.

Segundo ficou delineado pelo conjunto probatório, durante patrulhamento de rotina pelas ruas do Bairro Vila Esperança, na Cidade de Tatuí, policiais militares foram abordados por um morador do local, o qual lhes informou sobre a prática do tráfico de drogas levado a efeito por três indivíduos.

O delator anônimo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Tatuí-SP - cep 18278-440

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501241-36.2021.8.26.0571

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2252153/2021 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 20275483 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2159/21/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2252153 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DEIVIDE FOSTER e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

1º Juiz(a) de Direito Auxiliar: Dr(a). FERNANDO JOSE ALGUZ DA SILVEIRA

Vistos.

DEIVIDE FOSTER e WELLYNTON WESLEY GABRIEL NOGUEIRA, já qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso na figura típica descrita no artigo 35, combinado com o artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei nº 11.343/06 com incidência da agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porquanto, segundo narra a denúncia, no dia 15 de setembro de 2021, nesta Cidade e Comarca de Tatuí, associaram, entre si e com o adolescente

Wallace Willian Rocha de Oliveira (17 anos de idade), para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas.

DEIVIDE FOSTER e WELLYNTON WESLEY GABRIEL NOGUEIRA também foram denunciados e estão sendo processados como incursos na figura típica descrita no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei nº 11.343/06 com incidência da agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, pois, consoante relata a denúncia, no dia 15 de setembro de 2021, por volta das 12h00, na Rua Doutor José Afonso Tricla, nº 597, no Bairro Vila Esperança, nesta Cidade e Comarca de Tatuí, nas proximidades da Escola Ary de Almeida Sinisgalli, previamente ajustados, agindo em concurso, com unidade de desígnios, identidade de propósitos, entre si e com o adolescente Wallace Willian Rocha de Oliveira (17 anos de idade), traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 08 (oito) porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 73,88 gramas, 12 (doze) porções de "crack", subproduto da cocaína, com peso bruto aproximado de 2,45 gramas, 15 (quinze) porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 29,18 gramas, 02 (duas) porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 5,1 gramas, e 01 (uma) porção de "crack", subproduto da cocaína, com peso bruto aproximado de 0,17 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de 02 (dois) aparelhos de telefone celular e da importância de R\$ 254,80 (duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) em dinheiro.

Os réus foram notificados (fls. 264 e 323) e ofertaram suas defesas prévias (fls. 340/342 e 349/354).

A denúncia foi recebida no dia 10 de fevereiro de 2022 (fls. 357/359) e os acusados foram citados (fls. 383 e 396).

Durante audiência foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas e, ao final, os réus foram interrogados. A instrução foi encerrada e as partes ofertaram suas alegações finais orais (fls. 385/394).

Os autos vieram para a conclusão.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada que tramita em desfavor de DEIVIDE FOSTER e WELLYNTON WESLEY GABRIEL NOGUEIRA, os quais, segundo consta da peça inicial acusatória, em concurso material de delitos (artigo 69 do Código Penal), transgrediram os preceitos primários das normas penais incriminadoras inseridas no artigo 33, caput e no artigo 35, ambos combinados com o artigo 40, incisos III e VI, todos da Lei nº 11.343/06, com incidência da agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Cotejadas as provas colhidas nesta ação penal, conclui-se que os fatos descritos na denúncia não foram cabalmente demonstrados quanto ao delito de associação para o tráfico.

Por isso, de rigor o parcial acolhimento da pretensão punitiva com a condenação dos réus pela prática apenas do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, afastando, ainda, a incidência da agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, bem como a causa de aumento disposta no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, conforme será oportunamente explicitado.

Deveras, sabe-se que é necessário, para toda e qualquer condenação, que exista juízo exauriente acerca da autoria e materialidade delitiva.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está comprovada através do auto de prisão em flagrante delito de fls. 01/02, boletim de ocorrência de fls. 10/14, auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 17/18, imagens de fls. 31/65, laudo de exame químico toxicológico definitivo de fls. 226/231, comprovantes de depósito judicial de fls. 232 e 233, laudo pericial de fls. 299/306 e pela prova oral colhida.

De igual modo, a autoria em relação à infração penal apontada é inconteste.

Feitas as considerações iniciais, passa-se à análise da prova colhida em audiência.

Durante a instrução, a testemunha OTNIEL BARTA DA SILVA, policial militar, informou

que na data dos fatos sua equipe realizava patrulhamento pelas ruas do Bairro Vila Esperança. Em dado momento, foram abordados por um morador local que informou para eles que três indivíduos estariam comercializando drogas no citado bairro. Segundo o delator informou, os três indivíduos atuavam em forma de revezamento e, para tanto, enquanto um deles pulava em um terreno baldio situado na Rua Florindo Antunes Machado, os outros dois permaneciam na rua dando guarida à ação do comparsa. Após tomarem conhecimento das características dos suspeitos, efetuaram diligência e, na Rua José Afonso Tricta, lograram encontrar os acusados e o adolescente apontados na denúncia. Deivide estava defronte uma residência e, ao notar a aproximação da viatura, dispensou algo ao solo. O réu foi revistado e com ele foi encontrada a quantia de cento e quatorze reais em espécie. O material descartado pelo acusado consistia em duas porções de maconha. Com o acusado Wellynton Wesley foi localizada a quantia de cento e dez reais e oitenta centavos. Ao ser solicitada a retirada de seu tênis, discretamente o réu dispensou uma porção de crack que estava em sua meia. Já com o adolescente Wallace Willian apreenderam apenas a quantia de trinta reais em dinheiro. Com base na denúncia anônima, sua equipe diligenciou até o terreno baldio indicado como local de acondicionamento das drogas. Tratava-se de um terreno com a mata alta. Durante buscas, foi encontrado dentro de um buraco na parede doze porções de crack idênticas àquela dispensada por Wellynton Wesley. Um cão farejador da PM ainda localizou no terreno oito porções maiores de maconha e quinze porções menores da mesma substância e idênticas àquelas apreendidas com Deivide. Questionados, os três suspeitos negaram a prática da venda de drogas no local. Em seguida, os réus foram conduzidos à Delegacia de Polícia. Destacou que o bairro é conhecido como local de intenso comércio de drogas. Disse conhecer os acusados e o adolescente pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Indagado, asseverou que a denúncia recebida no dia dava conta do envolvimento dos réus e do adolescente, mas eles também praticavam o comércio espúrio de forma isolada ou com outras pessoas. Às indagações da Defesa informou que Deivide apenas mencionou que o dinheiro com ele localizado era proveniente da Adega de sua família. Salientou que a distância entre o local da abordagem e o terreno baldio em que as drogas eram acondicionadas é de aproximadamente trinta metros e que as Ruas Florindo Antunes Machado e José Afonso Tricta são ligadas por esquinas. A distância entre o local dos fatos e a escola Professor Ary de Almeida Sinisgalli é de três quarteirões.

O policial militar LEANDRO ROGÉRIO DELFINO MARTINS ratificou na íntegra o depoimento prestado por Otniel Barta da Silva.

O adolescente WALLACE WILLIAN ROCHA DE OLIVEIRA, testemunha arrolada pelos réus, disse conhecer o acusado Deivide. Já em relação ao réu Wellynton Wesley, o avistou no local, mas “não conhecia muito” (sic). Antes da abordagem já estava com os réus e haviam jogado futebol. Sabe que Wellynton Wesley reside próximo ao local dos fatos, mas desconhece seu envolvimento com o tráfico de drogas. Afirmou que Deivide também reside nas proximidades do local da abordagem e possui uma adega. O acusado Deivide realiza entregas, mas não sabe se ele estava trabalhando naquele momento. Indagado, contou fazer uso de maconha. Antes de serem abordados, estavam fumando maconha. Deivide já estava com um cigarro de maconha. Conhece Deivide há dois meses e sabia que ele utilizava drogas. Indagado pela Acusação, o depoente salientou que estava apenas fumando maconha. Não vendia drogas. Questionado sobre o teor de suas declarações no processo que tramitou pela Vara da Infância e Juventude relacionado aos mesmos fatos, disse que apenas mencionou ter feito uso de drogas no local e não assumiu a propriedade das drogas encontradas.

Por sua vez, perante a Autoridade Policial, o réu DEIVIDE FOSTER manifestou o desejo de permanecer em silêncio (termo de interrogatório de fl. 08). Durante seu interrogatório judicial, informou que já foi preso anteriormente pela prática do delito de tráfico de drogas. Residia na Rua Florindo Antunes Machado e trabalhava com vendas. Em relação aos delitos atribuídos em seu desfavor na denúncia, negou qualquer envolvimento. Disse que no dia dos fatos saiu para realizar uma entrega, parou em um local conhecido como ponto de venda de drogas, adquiriu duas porções de maconha e as guardou em seu bolso. Ao notar a chegada da viatura da PM, desesperado dispensou as drogas. Afirmou que não mais realizava a venda de drogas, mas é

usuário. O dinheiro com ele apreendido era fruto da venda de produtos de sua adega. Disse apenas conhecer de vista o corréu Wellynton Wesley e o adolescente. Não tinha amizade com ambos. Desconhece o que Wellynton Wesley e o adolescente estavam fazendo no local. Havia outra pessoa que não foi abordada. Conhece o PM Barta e já foi por ele aconselhado no passado. Sua esposa viu que estava sendo abordado e discutiu com os policiais.

O réu WELLYNTON WESLEY GABRIEL NOGUEIRA, em solo policial também se valeu do silêncio (termo de interrogatório de fl. 09). Em Juízo, contou que possui passagem pela Vara da Infância e Juventude pela prática de atos infracionais análogos aos delitos de furto e tráfico de drogas com imposição de medida socioeducativa de internação. Quanto aos fatos, negou a prática delitiva. Confirmou que o dinheiro que com ele foi apreendido lhe pertencia e era fruto de seu trabalho. Não possuía nenhuma porção de droga em sua meia e não é usuário. Reside no Bairro Vila Esperança e retornava de um jogo de bola. Encontrou com Deivide, pessoa por ele conhecida por morar no mesmo bairro, e parou para conversar. A viatura da Polícia Militar passou pelo local e efetuou a abordagem. Disse que não era conhecido pelos policiais que o prenderam. Havia outra pessoa no local, mas os policiais disseram que a denúncia recaía apenas sobre eles. Não acompanhou a apreensão das drogas no terreno. Não conhecia o adolescente, mas o cumprimentou porque estava com Deivide. Indagado, afirmou que já foi abordado diversas vezes pelos mesmos policiais. Mencionou já ter feito uso de maconha no passado. O dinheiro que com ele estava foi adquirido em data anterior. Reside com seu padrasto e sua mãe. Conhecia Deivide desde a infância, mas não sabe nada de sua vida.

Os depoimentos e os interrogatórios foram captados por meio de sistema audiovisual, nos termos do Provimento CGJ 08/2011 e das Leis nº 11.419/06 e 11.719/08, e através de videoconferência, mediante utilização do aplicativo Teams/Microsoft, com a disponibilização da mídia em pasta digital, em decorrência da pandemia do Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020.

Pois bem. Para uma melhor compreensão, procede-se à análise dos delitos imputados aos réus de forma individualizada.

DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 com incidência da agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal).

Ao final da instrução, em que pese o esforço das combativas defesas técnicas visando afastar a responsabilidade penal dos acusados, a prova coligida é robusta, clara e sólida a embasar o decreto condenatório no tocante ao delito de tráfico de drogas.

Segundo ficou delineado pelo conjunto probatório, durante patrulhamento de rotina pelas ruas do Bairro Vila Esperança, na Cidade de Tatuí, policiais militares foram abordados por um morador do local, o qual lhes informou sobre a prática do tráfico de drogas levado a efeito por três indivíduos.

O delator anônimo informou aos agentes públicos a forma como os vendedores dos tóxicos agiam, destacando que eles se revezavam e, enquanto um deles pulava em um terreno baldio situado na Rua Florindo Antunes Machado, os outros dois permaneciam na rua a fim de fazer campana e proteger o comparsa.

Orientados sobre as características dos suspeitos, os policiais militares seguiram ao local apontado para averiguação e, na Rua José Afonso Tricta, encontraram os acusados Deivide e Wellynton Wesley e o adolescente Wallace Willian.

Ao notar a presença da viatura, Deivide dispensou algo ao solo. Durante revista, com ele foi encontrada a quantia de cento e quatorze reais em espécie. O objeto por ele dispensado tratava-se de duas porções de maconha.

Em poder de Wellynton Wesley foi localizada a quantia de cento e dez reais e oitenta centavos. E, ao atender a ordem para a retirada de seu tênis, discretamente o réu dispensou uma porção de crack que estava em sua meia.

Com o adolescente Wallace Willian foi apreendida a quantia de trinta reais em dinheiro.

Em diligência no terreno baldio apontado pelo denunciante anônimo como local de armazenamento das drogas, os agentes públicos lograram encontrar dentro de um

buraco na parede doze porções de crack idênticas àquela dispensada por Wellynton Wesley.

Com o auxílio de um cão farejador da PM, também foram apreendidas no local oito porções maiores de maconha e quinze porções menores da mesma substância e idênticas àquelas apreendidas com Deivide.

Todos os envolvidos negaram envolvimento com o comércio de drogas.

Diante da constatação da infração penal, os réus foram presos em flagrante delito e conduzidos à Delegacia de Polícia para registro da ocorrência.

Tais questões estão embasadas pela prova testemunhal e demais elementos carreados aos autos.

As palavras dos agentes de segurança foram uníssonas e seguras acerca dos fatos retratados na denúncia, sendo certo que, nas oportunidades em que ouvidos, apresentaram versões concretas acerca da materialidade e autoria do delito perpetrado pelos réus.

Saliente-se, tanto doutrina quanto jurisprudência são uníssonas em afirmar que os depoimentos prestados por agentes de segurança devem ser críveis até prova em contrário. Os depoimentos prestados pelos guardas civis municipais, como servidores públicos que são, gozam de credibilidade, sendo seus testemunhos plenamente válidos, até porque inexistem impedimentos de ordem moral para afastá-los.

A esse respeito, observo que “Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunho ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes.” (RT 411/26).

Não obstante, frise-se que seus depoimentos foram submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.

As versões dadas pelos réus acerca dos fatos não merecem credibilidade, porquanto sequer guardam relação entre si.

Com efeito, o réu Deivide informou ser apenas usuário de drogas e, na data dos fatos, acabara de adquirir duas porções para seu uso. Ao perceber a aproximação da viatura da Polícia Militar, dispensou as porções, mas foi abordado. Salientou conhecer apenas de vista o corréu e o adolescente e não tem com eles amizade, bem como não sabe o que eles faziam no local.

Por seu turno, Wellynton Wesley negou os fatos, dizendo que não tinha nenhuma droga em seu poder. Asseverou não ser usuário de entorpecentes. Afirmou que retornava de um jogo de bola e encontrou com Deivide, pessoa por ele conhecida desde a infância e que mora no mesmo bairro. Cumprimentou o adolescente porque ele estava com o corréu, mas não o conhecia. Parou para conversar e todos foram abordados pela PM. Em um primeiro momento disse que os policiais não o conheciam, mas posteriormente destacou já ter sido abordado diversas vezes pelos mesmos agentes de segurança. Como visto, as versões dos acusados são extremamente incompatíveis, as quais não se prestam a influir em todos os elementos bem delineados pela prova coligida, notadamente em atenção aos seguros depoimentos prestados pelos agentes de segurança responsáveis pela diligência que culminou na constatação do ilícito.

Sequer a testemunha arrolada pela Defesa dos réus contribuiu para afastar a responsabilidade penal a eles imputada. Na verdade, o adolescente Wallace Willian apresentou versão diversa daquelas dadas pelos réus, indicando até mesmo fato não mencionado por eles, qual seja que havia sido feito uso de maconha no local e que Deivide já se fez presente ali com um cigarro da droga para consumir.

Ainda, como bem ponderou o Ministério Público, sequer o depoimento da testemunha guardou relação com sua declaração prestada nos autos do Processo que tramitou em seu desfavor na Vara da Infância e Juventude referente aos mesmos fatos aqui apreciados.

Neste viés, o depoimento não é apto a influir nos autos, merecendo total desprezo. Não pode também prevalecer a autodefesa do acusado Deivide no sentido de que as drogas que dispensou se destinavam ao seu consumo e, por consequência, não comporta acolhimento a desclassificação do delito a ele atribuído para aquele previsto no

artigo 28 da Lei nº 11.343/06, porquanto nenhum elemento de informação foi apresentado a fim de fomentar a alegada mera condição de usuário.

Em que pese tenha sugerido que é dependente químico, não apresentou qualquer documento médico ou, ainda, arrolou testemunhas que pudessem confirmar tal alegação, restando, pois, desprovida de credibilidade.

Não se olvida também que a quantidade de droga apreendida não se coaduna com a sustentada condição de dependência química.

Além do mais, o réu ostenta processo com condenação já transitada em julgado pela prática do delito de tráfico de drogas (Processo nº 0000611-59.2018.8.26.0571) e outro processo ainda em andamento, mas com sentença condenatória proferida em primeira instância, envolvendo o mesmo delito (Processo nº 1501750-36.2020.8.26.0624).

Não fosse isso, é indene de dúvidas que muitos usuários entram no tráfico para custear a compra de drogas para uso próprio (a denominada figura do "traficante-usuário"), situação que, por si só, não afasta a ilicitude do fato.

Tais questões fazem prevalecer a figura do traficante em detrimento à de usuário.

À vista de tais ponderações, evidente que as versões exculpatórias não se sustentam em face dos firmes depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência, os quais estão em consonância com os demais elementos constantes nos autos.

Diante de todo o contexto, inegável que a conduta dos acusados se amolda perfeitamente aos verbos-tipo "trazer consigo", "guardar" e "manter em depósito", previstos no preceito primário da norma penal incriminadora prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PROVA - SUFICIÊNCIA - Materialidade e autoria comprovadas - Réu preso em flagrante - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes - Conduta do apelante que se amolda ao verbo-tipo trazer consigo do artigo 33 da Lei de Drogas - Tipo misto alternativo em que basta que a conduta se subsuma a qualquer dos verbos-tipo para a caracterização da infração - Desnecessidade de dolo específico para a caracterização do tráfico - Negativa do réu isolada diante das demais provas coligidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - PENA - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - TRÁFICO PRIVILEGIADO - CIRCUNSTÂNCIAS ADVERSAS À CONCESSÃO DA BENESSE - "REFORMATIO IN PEJUS" - IMPOSSIBILIDADE - Aplicado pelo MM. Juízo redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar de um terço - Maus antecedentes do réu comprovados por Certidão - Impossibilidade de aplicação do redutor por expressa vedação legal - Recurso apenas da Defesa, o que impossibilita a "reformatio in pejus" - SENTENÇA - ERRO MATERIAL - CORREÇÃO - Determinação para que, no dispositivo da sentença, conste a condenação do réu por infração do artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343, de 23 de agosto de 2006, à pena de três anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de trezentos e trinta e três dias-multa, no valor mínimo legal - Sentença condenatória mantida, com retificação 'ex officio' - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 9090093-75.2008.8.26.0000, Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Relator(a): Desembargador(a) Amado de Faria; Origem: Comarca São José dos Campos; Julgamento e Publicação: 06.10.2011 e 13.10.2011) - sem destaques no original.

"Rejeição da Denúncia - Fundamento insubsistente - A conduta descrita na denúncia está tipificada no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - Quantidade de droga que autoriza a imputação - Princípio da insignificância que, por outro lado, não tem aplicação em nosso ordenamento jurídico, principalmente em se tratando do grave delito de tráfico de entorpecentes - Tratando-se de crime de ação múltipla, não é necessária a prática de atos de mercancia, bastando, para o seu reconhecimento, que se realize um dos verbos do tipo penal. Recurso provido a fim de receber aquela peça." (TJ-SP - Recurso em Sentido Estrito nº 0008243-89.2014.8.26.0050; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Relator(a): Desembargador(a) Marcos Corrêa; Origem: Comarca de São Paulo; Julgamento e Publicação: 30.04.2015 e 04.05.2015) - sem destaques no original.

"Tráfico de drogas. Autoria e materialidade do crime fartamente comprovadas. Exame

pericial constatando que a substância apreendida é cocaína. Palavra das testemunhas policiais e confissão do apelante de que guardava entorpecentes para terceiro. Configuração do ilícito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 posto que, independente da mercancia efetiva, esta é somente uma das possibilidades em meio aos múltiplos verbos nucleares do tipo, destinados a repreender todas as movimentações do narcotráfico, inclusive as de "ter em depósito" e "trazer consigo" drogas. Absolvição impossível. Penas bem dosadas, em observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/06. Apelo não provido." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 0001799-24.2013.8.26.0099; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Relator(a): Desembargador(a) Diniz Fernando; Origem: Comarca de Bragança Paulista; Julgamento e Publicação: 10.08.2015 e 15.08.2015) - sem destaques no original.

Convém lembrar mais uma vez não ser preciso para a caracterização da narcotraficância que o agente seja surpreendido no exato momento em que fornece materialmente a droga a terceira pessoa, bastando circunstâncias seguras de que para tanto se destina o tóxico com ele encontrado, como é o caso dos autos. A título de argumentação, ressalto que o fato de a ocorrência de um crime derivar de denúncia anônima (informantes) não obsta a que agentes de segurança tomem providências para apurar o fato.

Bem por isto, assentou o Supremo Tribunal Federal que a persecução penal pode ser deflagrada por denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados (HC nº 105.484, rel. Min. Cármen Lúcia; HC nº 99.490, rel. Min. Joaquim Barbosa; RHC nº 86.082, rel. Min. Ellen Gracie, entre outros).

Na mesma esteira há orientação doutrinária (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Anotado, RT, 12ª edição, pág. 96; José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, vol. I, Bookseller, pág. 135; Julio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado, Atlas, 11ª edição, pág. 99).

No caso vertente, além da delação de informante - anônimo -, houve um quadro de flagrante delito de tráfico de drogas, com a apreensão das drogas mencionadas na exordial acusatória.

Nesse sentido, a jurisprudência do E. TJSP:

"Apelação. Crimes de tráfico de drogas e receptação dolosa. Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. (...) O fato de a persecução penal ter sido encetada por denúncia anônima não configura qualquer nulidade, notadamente quando houve prisão em flagrante. Decisão judicial que apreciou a matéria. Preliminar rejeitada. (...). Recurso parcialmente provido." (TJ-SP 00160772520168260196 SP 0016077-25.2016.8.26.0196, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 03/08/2017, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/08/2017) (destaquei).

Ainda, o Código Penal adota a teoria unitária ou monista, na qual, todos os que concorrem para um crime por ele respondem. No caso dos autos, patente a atuação dos réus (pluralidade de indivíduos) e unidade de crime.

Como elucidado na denúncia, os réus, previamente ajustados, entre eles e com o adolescente Wallace Willian, agiram em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, estando presente o concurso de agentes previsto no artigo 29, caput, do Código Penal.

De mais a mais, as Defesas técnicas não produziram nenhuma prova que pudesse favorecer os acusados, limitando-se a postular as suas absolvições, teses estas devidamente rechaçadas, conforme tudo aqui exposto.

Não obstante, como salientado pelo membro do Ministério Público, a entidade informada na denúncia, qual seja a Escola Estadual Professor Ary de Almeida Sinisgalli dista a mais de duzentos metros do local da prisão dos acusados, extensão que também se revela superior ao espaço físico entendido como "imediações", a qual traz a ideia de acesso rápido e imediato. Por isso, o decote da causa de aumento disposta no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas se impõe. Neste sentido, inclusive: "TJ-SP - Apelação nº 0004512-19.2014.8.26.0363; 11ª Câmara de Direito Criminal; Relator(a): Ivana David; Origem: Comarca de Mogi-Mirim; Julgamento: 04.05.2016; Publicação: 24.05.2016".

De rigor, portanto, a condenação dos réus à prática do delito disposto no artigo 33, caput, cumulado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (Artigo 35 da Lei nº 11.343/06 com incidência da agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal).

No tocante ao crime previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, vislumbra-se que as provas amealhadas não se revelam aptas à edição de um édito condenatório, porquanto nada se demonstrou acerca de uma pretensa organização ou animus associativo entre os acusados.

O mero flagrante dos agentes na posse das substâncias entorpecentes, não autoriza a conclusão de que haja uma associação estável e constante para a prática delituosa. Com acerto a observação do eminente professor Vicente Greco filho, in Tóxicos, prevenção-repressão, 14ª edição, atual. e ampl., São Paulo, Ed. Saraiva, 2011: "Para haver crime autônomo de associação em matéria de entorpecentes é mister um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que determina a coautoria. É mister haja o dolo específico: associar para traficar (...) Diante, pois, destas considerações o crime de associação (art. 35) como figura autônoma há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores. Jamais a simples coautoria ocasional, transitória, esporádica, eventual configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração..." - sem destaque no original.

No mesmo sentido, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal, in verbis: "Para não confundir-se com o mero concurso de agentes, a melhor interpretação reclama à sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização, seja embora na preparação e no cometimento de um só delito de tráfico ilícito de drogas, hipótese que a sentença julgou provada." (STF, ROHC nº 75.236-5/AM, 1ª Turma, j. 3-6-1997, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 1º- 8-1997, RT 749/584, citado por Renato Marcão, Tóxicos, Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, Nova Lei de Drogas, Anotada e Interpretada, 7ª edição, Editora Saraiva, p.232) - sem destaque no original.

É que, como cediço, o crime de associação para o tráfico demandaria prova indubitável da existência de uma permanente e estável associação entre os acusados, para o fim da traficância, o que não foi produzido a contento nos autos. Tal figura típica, diferentemente da simples coautoria ou participação, exige a plena comprovação de que os agentes se achavam previamente associados com a intenção de praticarem o tráfico de drogas, sendo mister, para tanto, a apresentação de elementos probatórios da existência de situações anteriores, delimitadas no tempo e espaço, caracterizadoras da sociedade criminosa e sua permanência e constância.

Saliente-se que os Policiais Militares ouvidos em Juízo, disseram que estavam em "patrulhamento de rotina" e, acionados por um morador local, promoveram a abordagem dos réus e constataram a prática do tráfico ilícito de drogas.

Por isso, os elementos de informação não são hábeis a aferir com a necessária certeza a caracterização da estabilidade para a prática delitiva, motivo pelo qual as provas acusatórias não são suficientes para o acolhimento da imputação quanto ao delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, razão pela qual, a absolvição dos acusados com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP, neste sentido, é medida que se impõe.

DOSIMETRIA DA PENA.

Finda a fundamentação, passo à fixação da pena, adotando-se o critério trifásico, nos termos do art. 68 do Código Penal, observando, ainda, a Lei n. 11.343/06, atual Lei de Drogas.

RÉU DEIVIDE FOSTER.

Na primeira fase do critério trifásico, atento ao artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que o réu ostenta condenação anterior que

por caracterizar reincidência, nos termos da Súmula nº 241 do STJ, será ponderada na etapa seguinte.

Já a anotação inserta na certidão de fls. 69/70 referente ao Processo nº 1501750-36.2020.8.26.0624 deve ser desconsiderada nesta etapa, atentando-se ao verbete sumular nº 444, do STJ, segundo o qual “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Por outro lado, verifico que o grau de reprovabilidade da conduta do agente extrapolou o esperado pelo tipo penal em apreço, face à natureza, diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos em seu poder, frise-se, 08 (oito) porções de maconha com peso bruto de 77,71 gramas e líquido de 72,04 gramas; 15 (quinze) porções de maconha com peso bruto de 31,02 gramas e líquido de 26,09 gramas; 02 (duas) porções de maconha com peso bruto de 5,41 gramas e 4,45 gramas; 12 (doze) porções de crack com peso bruto de 2,25 gramas e líquido de 2,12 gramas; e 01 (uma) porção de crack com peso bruto de 0,19 gramas e líquido de 0,17 gramas (laudo de fls. 226/231).

Neste aspecto, inclusive, confira-se: “TJ-SP - Apelação Criminal nº 0028720-96.2014.8.26.0224; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Relator(a): Desembargador(a) Márcio Eid Sammarco; Origem: Comarca de Guarulhos - 5ª Vara Criminal; Julgamento: 06.06.2019; Publicação: 07.06.2019”.

Além disso, destaco que o crack possui efeitos deletérios àqueles que dele fazem uso com alta probabilidade de dependência imediata e catastrófica após a sua ingestão, bem como se apresenta extremamente nocivo à sociedade como um todo, tornando-se um problema endêmico de saúde pública em todo o território nacional. Assim, pautando-se pela proporcionalidade e razoabilidade exigida, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto) fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, assim como já declinado nos autos do Processo nº 1501160-87.2021.8.26.0571, ressalvado o entendimento até então adotado por este Juízo em relação à circunstância agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal (crime praticado em período de calamidade pública), passo a adequar-me à orientação recorrente provinda das Cortes Superiores no tocante à natureza subjetiva da referida agravante, razão pela qual entendo a sua não incidência no caso em comento.

Neste sentido, confira-se:

“Em relação à agravante prevista no art. 61, I, “j”, do Código Penal, verifica-se que a sanção do paciente foi novamente exasperada em 1/6, porque os fatos foram cometidos durante a pandemia do coronavírus, estado esse de calamidade pública; Todavia, entendo que deve ser afastada a referida agravante, pois sua incidência pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitativa.” (STJ - AgRg no HC 677.124/SP; 5ª Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julgamento: 03.08.2021).

“Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexos com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico.” (STJ - AgRg no HC 669.508/SP; 6ª Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julgamento: 15.06.2021).

De igual modo, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Veja-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena redimensionada - Afastamento da agravante da calamidade pública - Ausência de nexos causal - Regime prisional fechado mantido - Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP - Apelação Criminal nº 1501003-51.2020.8.26.0571; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal;

Relator(a): Desembargador(a) Jucimara Esther de Lima Bueno; Origem: Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal; Julgamento e Publicação: 15.02.2022).

“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE 47,1 GRAMAS DE COCAÍNA E 21,5

GRAMAS DE MACONHA - MERCANCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO CORRETA, POIS LASTREADA EM PROVA FIRME DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PENAS - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA "j" (calamidade pública) - NECESSIDADE. Não há prova de que o réu se valeu da pandemia causada pelo COVID-19 para praticar o delito - PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 1501141-18.2020.8.26.0571; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Relator(a): Desembargador(a) Willian Campos; Origem: Foro de Tatuí - 1ª Vara Criminal; Julgamento e Publicação: 01.09.2021).

Presente, por outro lado, a circunstância agravante da reincidência, conforme artigo 61, inciso I, do Código Penal (certidão de fls. 69/70 - Processo nº 0000611-59.2018.8.26.0571).

Ausentes circunstâncias atenuantes, deve a pena intermediária ser recrudesida em 1/5 (um quinto), chegando ao quantum de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de multa de 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa.

Justifica-se o recrudescimento apontado tendo em vista que o réu ostenta recidiva específica, revelando que está inserido no crime e busca apenas o lucro fácil da venda de drogas, o qual é altamente sedutor, dificultando o interesse de se levar uma vida reta.

Na terceira fase, incide a causa de aumento disposta no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, devendo a pena ser recrudesida de 1/6 (um sexto), gerando a reprimenda de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de multa de 815 (oitocentos e quinze) dias-multa.

O réu não faz jus à redução prevista na causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, porquanto não preenche os requisitos legais, porque é reincidente em crime doloso.

Não fosse isso, é certo que inquéritos e ações penais em curso não podem ser valorados a título de maus antecedentes, de modo a agravar a pena-base do réu por ocasião da análise das circunstâncias judiciais na primeira fase de dosimetria, tal qual já anteriormente assinalado. No entanto, o mesmo raciocínio não subsiste para o caso em que ele responde a processos análogos.

E, no caso, o réu possui processo em andamento pela sua incursão na prática de delito de igual natureza ao que se julga (certidão de fls. 69/70 - Processo nº 1501750-36.2020.8.26.0624), o que desponta para a dedicação do agente à atividade criminosa.

Ressalto que referido posicionamento encontra amparo no entendimento adotado pelo C. STJ, segundo o qual "a existência de processos em andamento são aptos a demonstrar que o agente se dedica a atividades criminosas, obstando a aplicação do redutor já mencionado" (STJ - REsp 1575321 SC 2015/0321747-3; Relator: Ministro NEFI CORDEIRO; DJ 20.06.2017).

Destarte, torno a pena definitiva em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de multa de 815 (oitocentos e quinze) dias-multa.

RÉU WELLYNTON WESLEY GABRIEL NOGUEIRA.

Na primeira fase, observo que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao acusado.

Diferentemente do réu Deivide, deixo de considerar a quantidade e a natureza da droga apreendida nesta fase, a fim de ponderá-las na terceira etapa da dosimetria da pena, notadamente para o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Justifico tal posicionamento de modo a evitar a incidência do bis in idem, em atenção ao entendimento firmado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese de que "as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena" (STF, Tema 712, publicado em 06.05.2014).

No mesmo sentido:

"Cumpre destacar que, em sessão realizada no dia 19.12.2013, o Pleno do STF, ao julgar os HCs 112.776 e 109.193, ambos da relatoria do Min. Teori Zavascki, firmou orientação no sentido de que, em caso de condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, a natureza e a quantidade da droga apreendida apenas podem ser levadas em consideração em uma das fases da dosimetria da pena, sendo vedada sua

apreciação cumulativa. Na ocasião, ficou consignado que cabe ao juiz escolher em qual momento da dosimetria essa circunstância vai ser levada em conta, seja na primeira, seja na terceira, observando sempre a vedação ao bis in idem. No presente caso, o Juiz de 1º grau, ao realizar a fixação da pena, levou em consideração a quantidade e a natureza da droga tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria para elevar a pena do recorrente, o que é vedado nos termos da jurisprudência desta Corte. Assim, manifesto-me pela existência de repercussão geral da questão constitucional debatida e pela reafirmação da jurisprudência desta Corte, de modo a fixar o entendimento no sentido de que as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena” (STF - ARE 666.334/AM; Rel. Min. Gilmar Mendes; j. 03.04.2014).

Por isso, fixo a pena-base em seu patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de multa de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa, como já declinado anteriormente, não há se falar no reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal (crime praticado em período de calamidade pública decretada pelo Governo Federal em decorrência da pandemia do coronavírus - Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020), eis que para sua incidência, dada a sua natureza subjetiva, deve haver provas concretas de que o acusado se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva, o que não se vislumbra na hipótese.

O réu faz jus à circunstância atenuante disposta no artigo 65, inciso I, do Código Penal, eis que na data do fato era menor de vinte e um anos. No entanto, deixo de considerá-la, pois a pena nesta etapa não pode ficar aquém do mínimo legal, em atenção ao teor da Súmula nº 231 do STJ.

Desta feita, a pena intermediária fica inalterada.

Na terceira fase, há a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, de modo que a reprimenda sofre aumento de 1/6 (um sexto), alcançando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de multa de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por outro lado, não há se falar em causas de diminuição de pena, notadamente a benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Apesar de primário, pelas circunstâncias em que se deu o flagrante ficou comprovado que os réus estavam dedicados à traficância. Embora não se tenham provas exatas, inconcussas, sobre a associação para o tráfico, situação não evidenciada no presente feito, ou ainda, a participação do réu em organização criminosa, evidente que, in casu, a quantidade de droga apreendida, sua diversidade e natureza, aliada ao concurso eventual de agentes, são fatores que não autorizam a incidência da benesse legal, pois demonstram que o acusado se dedica às atividades criminosas.

Acerca do tema, inclusive:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N.

11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA.

CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ENVOLVIMENTO NA TRAFICÂNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE

CRIMINOSA. INAFASTÁVEL A INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N.

666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME INICIAL

FECHADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. IMPOSIÇÃO JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL

DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal a quo negou o benefício, concluindo que o

ora agravante se dedicava à atividade criminosa do tráfico, diante da quantidade e da natureza droga apreendida e das circunstâncias do fato, de maneira que entender diversamente, como pretendido, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Inafastável a aplicação do enunciado n. 7 da Súmula desta

Corte. 2. Esta Corte tem decidido que a quantidade e a natureza da droga, aliadas

às circunstâncias em que cometido o tráfico, podem evidenciar a dedicação a

atividades criminosas, o que afasta a aplicação da minorante. In casu, a utilização

da quantidade/natureza da droga apreendida para elevar a pena-base (primeira fase)

e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de

Drogas (terceira fase), por demonstrar que o acusado se dedica a atividades

criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem. Diversa é a hipótese tratada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade/natureza da droga “tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014). 3. A quantidade e natureza da droga apreendida – 500 invólucros de cocaína e 9 porções de maconha – constituem fundamentos idôneos para o agravamento do aspecto qualitativo da pena, ou seja, para a fixação de regime mais gravoso (fechado). 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 1630521 SP 2019/0362668-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: DJe 09/06/2020).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE CONDENADO À PENA CORPORAL DE 5 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL FECHADO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONDENAÇÃO PROVISÓRIA ANTERIOR. OFENSA À SUMULA N. 444 DESTA CORTE. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE DEDICA-SE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MONTANTE DA PENA QUE NÃO PERMITE O BENEFÍCIO. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PRIMARIEDADE QUE ENSEJAM O REGIME INICIAL SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) - Esta Corte Superior tem decidido que a quantidade, a variedade e a nocividade da droga, bem como as circunstâncias nas quais foi apreendida, são elementos que evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa e, em decorrência, podem embasar o não reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. - Hipótese em que inexistente ilegalidade quando da não aplicação do privilégio, pois a Corte local apontou a dedicação do paciente às atividades ilícitas, destacando a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos e as circunstâncias em que o delito ocorreu, notadamente agravadas pelo fato de o acusado contar com condenação provisória pela prática do mesmo delito e por terem sido apreendidos 536 tubos plásticos vazios. Modificar tal conclusão requer o revolvimento fático probatório, inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes.” (STJ, HC 374992 / SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 07/02/2017) - destaquei.

Não fosse isso, o acusado dedica-se ao comércio ilícito desde a menoridade. Com efeito, infere-se do seu interrogatório e da certidão de fls. 74/75, passagens pela Vara da Infância e Juventude, notadamente pela prática de ato infracional análogo ao crime em questão e com aplicação de medida socioeducativa de internação.

De fato, é certo que registro de ato infracional não se presta a gerar maus antecedentes ou reincidência. Não obstante, é apto e suficiente para afastar a incidência do tráfico privilegiado, pois denota que sua conduta tem sido permeada pela prática de atos antissociais.

Neste viés, inclusive, “... conquanto o ato infracional (...) não possa ser considerado para fins de reincidência, ou mesmo como maus antecedentes, serve perfeitamente para demonstrar sua periculosidade, bem assim sua propensão ao cometimento de delitos da mesma natureza (...)” (HC 33614/DF; 5ª Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; j. 2-6.2005; DJ 20-6-2005; p. 302).

Ainda:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO E NÃO EXCEDENTE A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DO ENTORPECENTE. MODO INTERMEDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE PARCIALMENTE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não

cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n.11.343/2006). 3. Concluído pela instância antecedente, diante de anterior registro de ato infracional análogo ao delito de tráfico de entorpecentes, que o paciente se dedica a atividade criminosa, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Conforme entendimento do